

1505768-87.2021.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 11/02/2022

... em crimes de elevada gravidade como o de tráfico de drogas, cujas testemunhas se abstêm de prestar declarações às autoridades policial ou judicial por respeito à "lei do silêncio" e por temor a represálias. Nesse sentido, a propósito, é a pacífica posição da jurisprudência do E. TJSP:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Preliminar de cerceamento de defesa, no caso, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1505768-87.2021.8.26.0132 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505768-87.2021.8.26.0132

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2279651/2021 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 20805701 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO,

4953/21/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2279651 - DEL.INV.GER. CATANDUVA,

4953/21/708 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE DAMIÃO BUENO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou Alexandre Damião Bueno dando-o como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06, pois, no dia 13 de outubro de 2021, por volta das 20h30, na Rua Rio Grande da Serra, n. 522, Jardim Eldorado, nesta cidade e Comarca, em sua residência, ele guardava três porções de maconha e cultivava cinco vasos com arbustos de cannabis sativa, com o fim de mercancia, bem como mantinha petrechos e anotações relacionadas à traficância de drogas (fls. 89/90).

A prisão em flagrante do réu foi convertida em preventiva no dia 14 de outubro de 2021, em sede de audiência de custódia (fls. 39/41).

Em sede de defesa preliminar, em suma, é pleiteada a desclassificação da imputação e a instauração de incidente de exame de dependência toxicológica (fls. 95/111). A denúncia foi recebida em 30 de novembro de 2022, ocasião em que foi rejeitado o pedido de instauração do incidente de exame de dependência toxicológica (fls. 120/122).

No curso da instrução processual foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o acusado, que assumiu a propriedade da droga, cujo fim seria seu consumo pessoal. Por ocasião do momento processual do art. 402 do CPP as partes nada requereram. Em alegações finais, o Ministério Público requer a procedência da pretensão punitiva estatal, com o reconhecimento da agravante da reincidência. A Defesa, por seu turno, suscita a insuficiência probatória e, subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da imputação ou a fixação da reprimenda no patamar mínimo. É o relatório.

Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausentes questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, passo ao exame do mérito. Diante do arcabouço probatório produzido, a pretensão punitiva deve ser julgada parcialmente procedente.

No ponto, impende se assentar que o juízo condenatório depende da prova clara, segura, convincente e além da dúvida razoável. Trata-se de lição extraída do basilar princípio do in dubio pro reo, que, por sua vez, decorre do direito fundamental à presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF). No ponto:

O in dubio pro reo não é, portanto, uma simples regra de apreciação das provas. Na verdade, deve ser utilizado no momento da valoração das provas: na dúvida, a decisão tem de favorecer o imputado, pois não tem ele a obrigação de provar que não praticou o delito. Enfim, não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se - para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica - em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet.

Essa certeza necessária à condenação, conforme se depreende da lição insculpida no art. 155 do CPP, deve decorrer dos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa - não obstante os elementos informativos coletados no curso da investigação policial possam servir como mecanismo de fortalecimento da prova e, assim, atuar no convencimento do julgador. O que não se aceita, à evidência, é o decreto condenatório lastreado única e exclusivamente em elementos informativos, salvo quando estes consistem em verdadeiras provas cautelares, irrepetíveis ou antecipadas.

No caso, não obstante o empenho do Ministério Público, é de rigor reconhecer que o conjunto probatório é falho, lacunoso e inábil a firmar o convencimento acerca da conduta de traficância de drogas.

Com efeito, as argumentações acusatórias, em apertada síntese, são de que informalmente o acusado confessou a prática da traficância aos policiais militares, de que terceiras pessoas o indicaram aos policiais militares como traficante, de que havia acessórios para o acondicionamento das substâncias entorpecentes e que a quantidade de droga é expressiva.

Porém, como assentado, tais dados são duvidosos.

No tocante ao "interrogatório informal", realizado pelos policiais militares, em via pública, sem documentação e preservação mínima dos direitos e garantias fundamentais, trata-se de ato que, a rigor, é totalmente desprovido de valor probante, especialmente quando vai de encontro ao constante do termo de interrogatório policial e judicial.

À toda evidência, a busca da verdade no processo penal se sujeita a limitações e regras precisas voltadas ao controle sobre a atividade jurisdicional e o poder de punir do Estado. Uma dessas limitações, de feição ética, ao poder-dever de investigar a verdade dos fatos é, precisamente, a impossibilidade de obrigar ou

induzir o réu a colaborar com sua própria condenação, por meio de declarações ou fornecimento de provas que contribuam para comprovar a acusação que pesa em seu desfavor. Daí a razão de a Constituição prever que qualquer pessoa, ao confrontar-se com o Estado em sua atividade persecutória, deve ter a proteção jurídica contra eventual tentativa de induzi-lo a produção de prova favorável ao interesse punitivo estatal, especialmente se do silêncio puder decorrer responsabilização penal do próprio depoente.

Tamanha a relevância da temática em questão que há tempos ela toma o foco da jurisprudência nacional, de modo que no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, cristalizou-se o entendimento de que nenhuma pessoa, uma vez confrontada com a atividade persecutória estatal, poderá ser compelida a produzir prova contra si mesma. No ponto:

O direito à não autoincriminação consiste na prerrogativa do investigado ou acusado a negar-se a produzir provas contra si mesmo, e a não ter a negativa interpretada contra si. No caso, interessa o direito ao silêncio, o aspecto mais corrente do direito à não autoincriminação. Por projeção, o direito ao silêncio consistente na prerrogativa do implicado a recusar-se a depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio seja interpretado como admissão de responsabilidade. (STF, ADPF nº 444, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, J: 14/06/2018, DJe: 22/05/2019)

Importa ainda ressaltar que, sem embargo de posicionamentos distintos do próprio E. TJSP, para além da observância do direito ao silêncio no âmbito dos interrogatórios formais, ou seja, aqueles prestados perante as autoridades policial e judiciária, a advertência do direito ao silêncio deve ser realizada também pelos policiais responsáveis pela “voz de prisão” – conforme decidido pelo STF no bojo do RHC 192798 AGR/SP.

Ora, no caso em testilha, quando interrogado pela autoridade policial – a qual, diferentemente dos policiais militares, possui a atribuição de realizar tal ato –, o acusado afirmou que a droga apreendida se destinava exclusivamente ao seu consumo pessoal (fl. 04), versão que ratificou em Juízo.

Logo, fazer prevalecer uma suposta confissão informal, colhida ao arrepio das formalidades inerentes ao ato, em detrimento do interrogatório policial e judicial é medida absolutamente descabida que remete ao já não mais concebido Estado policalesco. Do contrário, seria desnecessário interrogar o acusado ou mesmo produzir outras provas em Juízo, eis que a narrativa dos policiais militares, simples e puramente, seria sempre suficiente ao deslinde da demanda.

Da mesma forma, conquanto os policiais militares narrem que chegaram ao endereço do acusado após a realização da prisão de duas pessoas que lhes notificaram a prática do tráfico de drogas por ele, inexplicavelmente não consta dos autos qualquer qualificação dessas pessoas, que poderiam e deveriam ter sido ouvidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ou ao menos em sede policial, inclusive para amparar a pretensão acusatória. Houve, nesse ponto, inequívoca perda de uma chance probatória pelo Ministério Público.

No ponto, não se olvida que, conquanto não sejam dotados de presunção processual de veracidade nem possuam valor probatório superior às demais provas admitidas no campo do processo penal, os testemunhos dos policiais responsáveis pela prisão não podem ser indistintamente desconsiderados tão somente pela natureza da função que exercem, sobretudo quando coesos e uniformes, como no caso. Memora-se, também, que nas ações penais lastreadas em autos de prisão em flagrante corriqueiramente as únicas testemunhas são exatamente os policiais responsáveis pela prisão, especialmente em crimes de elevada gravidade como o de tráfico de drogas, cujas testemunhas se absterem de prestar declarações às autoridades policial ou judicial por respeito à “lei do silêncio” e por temor a represálias. Nesse sentido, a propósito, é a pacífica posição da jurisprudência do E. TJSP:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Preliminar de cerceamento de defesa, no caso, confunde-se com o mérito. Ausência de prova do prejuízo. Absolvição.

Materialidade e autoria comprovadas. Conjunto probatório firme e seguro a demonstrar a destinação mercantil da droga. Valorização das palavras dos policiais responsáveis pela prisão dos réus. Impossibilidade de desclassificação do crime

para o de porte para uso próprio. Penas inalteradas. Artigo 41 da Lei de Drogas. Afastamento. Réu não colaborou com as investigações. Regime prisional mantido no fechado. APELO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500606-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cajuru - Vara Única; Data do Julgamento: 04/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020) Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição. Depoimentos de policiais. Necessidade de prestigiar o testemunho do agente público, mormente quando não há razão para infirmá-lo. Razoável quantidade de drogas e circunstâncias da prisão – Reprimenda. Redução. Afastamento da circunstância judicial desfavorável. Quantidade de droga que não pode ser considerada expressiva – Apelo parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500097-75.2019.8.26.0610; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Morro Agudo - Vara Única; Data do Julgamento: 13/11/2020; Data de Registro: 13/11/2020)

Logo, é plenamente possível a imposição do decreto condenatório com base na palavra dos policiais – o que, aliás, corriqueiramente é aplicado neste Juízo. Todavia, isso só é viável quando o cenário fático indique a inexistência de outras provas passíveis de produção, ao alcance da acusação, sob pena de, como já assentado, se tornar inócua a produção probatória, que se reduziria à repetição das declarações das autoridades públicas, recebidas como verdades intocáveis.

Além do mais, ao deliberadamente deixar de qualificar essas relevantes testemunhas, houve inequívoco prejuízo à plena instrução processual, sobretudo sob viés de produção de contraprovas pela Defesa.

No mais, o Ministério Público atenta para a apreensão de apetrechos utilizados no acondicionamento das drogas. E, de fato, consultando-se o auto de exibição e apreensão (fls. 22/23), constata-se a apreensão de um rolo de plástico-filme, uma tábua de carne com resquícios de maconha e uma caderneta de anotações atinentes à contabilidade do tráfico.

Porém, o rolo de plástico-filme e a tábua de carne, por si sós, não permitem concluir pela traficância de drogas, eis que também podem ser empregados pelo consumidor de entorpecentes para o manuseio, separação e manutenção da substância – sobretudo quando há o cultivo da matéria. A propósito, o acusado apresentou justificativa plausível para a existência de resquícios de maconha na tábua e o uso do papel filme para embalar sua droga de consumo pessoal.

Não houve, lado outro, apreensão de balança de precisão – utensílio que seria essencial à atividade do acusado, caso ela se desenvolvesse do modo narrado na denúncia

E, o que mais merece destaque, é apreensão de um caderno de anotações da contabilidade do tráfico – o qual não foi juntado aos autos, de modo que não se tem qualquer notícia concreta acerca do teor das anotações constantes desse caderno.

Mais uma vez, houve perda da chance probatória pela acusação que, ao não se desincumbir do seu ônus e requisitar o documento, também tolheu o direito de contraprova da Defesa.

Aliás, vale ressaltar que o policial militar Osmir Class foi diretamente perguntado pelo Juízo acerca da apreensão do caderno de anotações e, respondeu não recordar de tal objeto, ao passo que o policial militar Rogério Barbosa da Silva também não faz qualquer menção ao documento. O réu, por sua vez, nega que possuísse caderno de anotações.

De mais a mais, embora a quantidade da droga não seja reduzida, a sua natureza é única não alcança patamar que torne inafastável sua destinação para consumo pessoal.

Com efeito, os policiais militares narraram em Juízo que no domicílio do réu encontraram apenas cinco vasos com pés de maconha e algumas porções já preparadas, em reduzida quantidade. Frise-se que o policial militar Rogério Barbosa da Silva expressou que a quantidade de droga preparada era pequena.

Do auto de exibição e apreensão se denota que a estufa apreendida era pequena (“estufa com luz artificial, pequena para cultivar plantas” - fls. 22/23), do que se depreende que era inviável a produção em larga escala e até mesmo lucrativa, tendo em vista o lapso temporal de crescimento das plantas e a quantidade de

substância dela extraída.

Ademais, do laudo de constatação definitiva de substância entorpecente consta que a massa líquida da substância apreendida é de 71g (fls. 54/56), ao passo que, de forma duvidosa, do laudo de constatação provisória consta a massa líquida de aproximadamente 183g. Deve prevalecer, à toda evidência, o laudo definitivo.

De uma ou outra forma, considerando a condição do acusado de usuário de drogas e que parcela das substâncias apreendidas estava em forma de planta, em cultivo artesanal e de baixa escala, não há como se considerar a quantidade elevada a ponto de possibilitar mercancia lucrativa. Ainda que assim não fosse, é lição que decorre do disposto no art. 28, §2º, da Lei 11.343/06 que a quantidade de droga apreendida, isoladamente, não serve para caracterizar a traficância. E, na hipótese em tela, não se evidenciam dados concretos, submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, a justificar a acusação.

Além disso, outra vez mais há tolhimento da possibilidade de contraprova diante da ausência de documentação ou mesmo inquirição das pessoas que teriam delatado o acusado aos policiais militares, eis que estes afirmaram não recordar qual tipo de droga tais pessoas portavam – se era maconha (única apreendida com o réu) ou outras.

Logo, diante das circunstâncias do caso (um tipo de droga, mantido no interior da residência, sem constatação de movimentação de usuários e apreensão de balança de precisão) e da lacunosa e fraca prova produzida ao longo da instrução criminal, sobretudo em razão da impossibilidade de recebimento das palavras dos policiais como verdades absolutas que dispensam a produção das outras provas que estavam acessíveis, subsiste dúvida acerca da destinação das drogas apreendidas.

Nesse sentido, a propósito, já se posicionou o E. TJSP:

TRÁFICO. Apelo defensivo que pretende a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Necessidade de reforma. Apreensão de pequena quantidade de drogas (total de 55 porções, somando aproximadamente 70g de maconha e cocaína). Condenação calcada na existência de registros de múltiplas ligações telefônicas para um conhecido traficante da cidade. Insuficiência. Milhares de páginas de informações extraídas do telefone celular do apelante que não contêm uma referência sequer ao comércio ilícito. Versão de que teria adquirido as drogas para consumo pessoal razoável e compatível com as circunstâncias da apreensão, inclusive a quantidade e variedade de entorpecentes apreendida. In dubio pro reo. Apelo provido para desclassificar a conduta para aquela do art. 28 da Lei de Drogas, com anulação da condenação e abertura de vista ao Ministério Público, a fim de que possa avaliar a possibilidade de oferecer benefícios despenalizadores. Recurso ministerial prejudicado. (TJSP; Apelação Criminal 1500333-58.2020.8.26.0556; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Iacanga - Vara Única; Data do Julgamento: 08/02/2022; Data de Registro: 08/02/2022) Também é a linha decisória do C. STJ:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVAS DE AUTORIA INSUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. 1. Admite-se, em recurso especial, a desclassificação do delito quando para tanto bastar a reavaliação dos fatos e provas delineados no acórdão, como no caso em exame. Precedente. 2. Na espécie, a condenação do réu foi justificada na apreensão da droga, na prisão em flagrante, bem como no depoimento prestado em juízo pelos policiais de que encontraram os entorpecentes na geladeira localizada na residência do acusado. Não foram localizados petrechos comuns ao tráfico de entorpecente, tais como balança de precisão, calculadora, entre outros. Baseou-se a sentença apenas na apreensão dos entorpecentes, cuja quantidade ajusta-se ao que prescreve o art. 28 da Lei de Drogas. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1943090/AC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 26/11/2021)

Portanto, de rigor acolher o pleito defensivo para desclassificar a imputação a fim de amoldá-la ao disposto no art. 28, caput e §1º, da Lei 11.343/06.

Eis que se trata de agente reincidente, prescindível a abertura de vista dos autos ao Ministério Público para a proposição das benesses da Lei 9.099/95, pois inequivocamente descabidas.

No que tange à aplicação da pena, na primeira fase, à luz do disposto no art. 42 da Lei 11.343/06 e no art. 59 do CP, não se vislumbram circunstâncias desfavoráveis. Na segunda fase, denota-se a incidência da atenuante da confissão e a agravante da reincidência. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição. Logo, cabível e adequada a aplicação da reprimenda de prestação de serviços à comunidade pelo período de 03 meses e 25 dias.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para, com a desclassificação da imputação inicial, CONDENAR o acusado Alexandre Damião Bueno como incurso nas sanções do art. 28, caput e §1º, da Lei 11.343/06 à reprimenda de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 03 meses e 25 dias.

Visto que a prisão cautelar do agente perdurou por prazo superior ao da reprimenda em questão, com base no art. 387, §2º, do CPP, c.c art. 66, II, da Lei 7.210/84, DECLARO extinta a punibilidade pelo integral cumprimento da pena. Expeça-se alvará de soltura clausulado, com urgência.

Por força dos princípios da correlação e do contraditório, deixo de fixar valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

Em observância ao art. 72 da Lei 11.343/06, determino a destruição das amostras de substância entorpecente guardadas para contraprova, com certificação nos autos.

Ausentes provas da procedência ilícita do numerário apreendido nos autos, determino a restituição ao acusado. Quanto aos demais objetos despidos de valor econômico e utilizados para o manuseio e acondicionamento da droga (tábua e papel-filme), determino a destruição.

Custas a cargo do réu (art. 604 do CPP), sem embargo da suspensão decorrente da gratuidade de Justiça, que ora reconheço.

Com o trânsito em julgado, archive-se.

P. I. C., com observância do art. 392 do CPP.

Catanduva, 11 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA